Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0522.13.000319-0/001	**Númeração**	0003190-
Relator:	Des.(a) Amauri Pinto Ferreira		
Relator do Acordão:	Des.(a) Amauri Pinto Ferreira		
Data do Julgamento:	16/01/2014		
Data da Publicação:	27/01/2015		

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES, SEM VISTA À DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

- A juntada de documentos pela acusação, nas contrarrazões, sem vista à defesa sobre tais documentos, ocasiona cerceamento de defesa, ensejando a nulidade absoluta do feito, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

- Preliminar de nulidade acolhida.

V.V.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 - PRELIMINARES - NULIDADE DO PROCESSO - DESRESPEITO ÀS REGRAS DE CONEXÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO - CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE NÃO CARACTERIZADAS - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - CORREÇÃO DE OFÍCIO. -Uma vez proferida sentença definitiva em um dos feitos, não há falar em conexão, pois, nesse

caso, a unidade dos processos somente ocorrerá em sede de execução, nos termos do disposto no art. 82 do CPP. -Para que haja a configuração do estado de necessidade, é mister que haja uma situação de perigo atual, o que não ocorreu no caso em comento. -É pouco crível que uma pessoa de diligência normal desconheça a proibição de se portar arma de fogo sem a devida autorização legal, mormente após a grande repercussão gerada em torno da campanha pelo desarmamento. -A redução, nesta seara recursal, do valor da prestação pecuniária imposta ao apelante na sentença afigura-se francamente inoportuna, nada impedindo, contudo, que o acusado formule o pedido que entender conveniente perante o Juízo da Execução. -Constatado erro material na fixação da pena, deve-se proceder à sua correção de ofício.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0522.13.000319-0/001 - COMARCA DE PORTEIRINHA - APELANTE(S): TEDY TARICK SILVA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, por maioria, vencido o em. Des. Relator, em ACOLHER A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. AMAURI PINTO FERREIRA (JD CONVOCADO)

RELATOR.

DES. DOORGAL ANDRADA

RELATOR PARA O ACÓRDÃO.

DES. AMAURI PINTO FERREIRA (JD CONVOCADO) (RELATOR)

Trata-se de apelação criminal interposta por TEDY TARICK SILVA inconformado com a r. sentença de f. 74/76 que o condenou nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03, às penas definitivas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Narra a denúncia que no dia 22 de janeiro de 2013, por volta de 06h00, na Rua Mestre Silvano, nº 501, Bairro Eldorado, na Comarca de Porteirinha/MG, Tedy Tarick Silva foi flagrado de forma livre e consciente possuindo e mantendo sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.

Segundo a inicial acusatória, na data supramencionada policiais militares compareceram à residência do acusado de posse de seu mandado de prisão, bem como de mandado de busca e apreensão. Após efetuarem a prisão do réu, os milicianos procederam às buscas pelo imóvel, ocasião na qual encontraram, entre os pertences de Tedy Tarick Silva, um revólver, marca Taurus, calibre 22, número de série 42540, cano único medindo 57 milímetros de comprimento e tambor com capacidade para 06 (seis) cartuchos. Além da arma, foram apreendidas também 07 (sete) munições para arma calibre 22, uma munição para arma calibre 25 e 06 (seis) munições para arma calibre 38, todas intactas. Consta da exordial que a arma de fogo foi apreendida e periciada, oportunidade em que os peritos constataram que essa estava em perfeitas condições de uso.

Após regular instrução, a d. Sentenciante julgou procedente a inicial acusatória para condenar o réu nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Pleiteia a defesa, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo, por desrespeito às regras de conexão, ou em razão da

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugna pela absolvição, ao argumento de ter agido em estado de necessidade e por ter incorrido em erro quanto à ilicitude do fato. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa e da prestação pecuniária.

Contrarrazões ministeriais, manifestando pela manutenção integral do decisum, f. 103/107.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 121/122, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inicialmente, acuso o recebimento do memorial apresentado em meu gabinete, cujos argumentos foram sustentados da Tribuna pelo nobre Advogado, Dr. Aloysio Fernandes Ximenes Carneiro, e que passo, agora, a analisá-los.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e processamento.

Preliminarmente, pugna a defesa pela declaração de nulidade do processo, face ao desrespeito às regras de conexão. Para tanto, aduz que o presente processo se originou do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido em razão da suspeita do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, ocasião na qual a arma de fogo foi apreendida. Sustenta que o representante do Parquet deveria, então, ter apresentado uma única denúncia, abarcando os dois ilícitos, vez que esses teriam sido praticados no mesmo lugar e no mesmo dia.

Todavia, não vislumbro, data venia, a conexão aventada pela defesa.

Conforme se verifica das provas constantes dos presentes autos, o fato em julgamento não guarda relação com o delito de tráfico de

drogas, não restando configuradas, assim, quaisquer das hipóteses previstas no art. 76 do Código de Processo Penal.

In casu, apura-se que os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar foram expedidos em desfavor de Tedy Tarick Silva, em razão de investigações sobre o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes. E ao dar cumprimento aos referidos mandados, os policiais apreenderam a arma de fogo, o que deu causa à presente ação penal.

E o ora apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse que o delito de tráfico fora perpetrado na mesma data do crime ora em julgamento. Nesse aspecto, cabe salientar que não foram apreendidas substâncias entorpecentes na residência do réu, conforme se verifica da denúncia de f. 01-D/03-D.

Ademais, ainda que houvesse conexão, uma vez proferida sentença definitiva em um dos feitos, como é o caso, a unidade dos processos somente deve ocorrer em sede de execução, nos termos do disposto no art. 82 do CPP:

"Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas."

Essa é a orientação constante do enunciado da Súmula nº 235 do STJ, in verbis:

"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

Destarte, rejeito a preliminar.

Ainda em sede prefacial, aduz a defesa que o representante do

Parquet, ao apresentar as contrarrazões, juntou aos autos prova emprestada, fato que ensejaria a nulidade do feito, vez que não foi dada vista à defesa, causando-lhe prejuízo.

Todavia, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que tais documentos não foram por mim considerados quando da análise do presente recurso. Por conseqüência, julgo desnecessário determinar o desentranhamento das provas, as quais em nada influenciaram no deslinde da causa.

Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o recurso defensivo não merece provimento.

Cabe ressaltar que a materialidade delitiva é inconteste, conforme demonstram o APFD, f. 02-A/05, o auto de apreensão, f. 09, o boletim de ocorrência, f. 10/15, e os laudos periciais, f. 24/27, tudo em perfeita harmonia com as demais provas dos autos.

Já em relação à autoria, tenho que essa também se mostrou incontroversa.

O próprio acusado confessou, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, f. 05 e 79/80, a prática do delito narrado na exordial, in verbis:

"(...) PERGUNTADO sobre as munições e a arma de fogo que foram localizadas na residência do declarante nesta data RESPONDEU 'o revólver cal. 22 e as munições de cal. 22 são minhas, sobre as outras eu não sei não; (...)" (Tedy Tarick Silva, f. 05)

"(...) que a denúncia é verdadeira; que confirma suas declarações prestadas na fase policial de f. 05, lidas neste ato e que passam a fazer parte integrante deste; (...) que comprou a arma apreendida em razão de já ter sido assaltado duas vezes, tendo tomado trauma; que já tinha a mencionada arma há cerca de três anos; (...)" (Tedy Tarick Silva, f. 79/80)

A testemunha Valdir Soares de Souza, em Juízo, afirmou que "acompanhou os policiais no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu e verificou a apreensão de um revólver calibre 22", f. 77.

Destarte, não resta dúvida acerca da autoria. Aliás, nesse aspecto a defesa em nada contesta, pugnando, entretanto, pela absolvição, ao argumento de que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal, qual seja, o estado de necessidade.

Entretanto, não estão presentes, no caso em comento, os requisitos que caracterizam a referida causa de justificação.

Para que se configure o estado de necessidade, é mister que haja um perigo atual e inevitável. Segundo o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, em sua obra "Tratado de Direito Penal"; Parte Geral, Volume 1; 9ª edição; Saraiva, 2004, p. 313:

"Perigo passado ou futuro não pode justificar o estado de necessidade. Se o dano ou perigo já se efetivou, a ação do agente somente estará legitimada para impedir sua continuação. Se o perigo for futuro, poderá até não se concretizar; se for passado caracterizará vingança. Em qualquer das hipóteses falta-lhes a característica da atualidade, permitindo a utilização de outros recursos."

Em Juízo, o apelante, ao confessar a posse da arma de fogo, alegou "que comprou a arma apreendida em razão de já ter sido assaltado duas vezes, tendo tomado trauma", f. 79/80.

Entretanto, tal motivação não consubstancia o estado de necessidade, vez que baseada em uma situação de perigo pretérita, e não atual.

Ademais, cabe ressaltar que é dever do Estado garantir a segurança pública, não cabendo ao cidadão comum se armar, sem a

devida autorização legal, sob pena de instalação de um verdadeiro caos social. O fito da Lei do Desarmamento é, justamente, garantir a pacificação da sociedade. É cediço que a diminuição dos índices de criminalidade está diretamente ligada às medidas de restrição ao uso de arma de fogo. Portanto, compete ao cidadão, que se sentir ameaçado, comunicar o fato à autoridade competente, agindo, dessa forma, conforme ao direito.

Nessa esteira de pensamento, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. DESCABIMENTO.- A Lei 10.826/2003 não afronta a Carta Magna de 1988 e, ao revés, está em perfeita sintonia com a ordem constitucional, já que ao aumentar a reprovabilidade do porte ilegal de arma de fogo, evitando que vidas inocentes sejam ceifadas pela banalização do uso das armas, reafirmou a proteção prioritária que o Estado dispensa à vida dos seres humanos.- O ordenamento jurídico não comporta as excludentes de 'legítima defesa preventiva' ou 'estado de necessidade virtual', de forma que a simples alegação de que o acusado transitava por locais perigosos e poderia, a qualquer momento, ser atacado por outrem, não é motivo suficiente para excluir a ilicitude do porte ilegal de arma de fogo." (Apelação Criminal nº 1.0702.07.392193-5/001; Relator Desembargador Renato Martins Jacob; Julgado em 29/01/2009 e Publicado em 10/02/2009)

Também não prospera o pleito defensivo referente ao reconhecimento da excludente de culpabilidade, consubstanciada no erro de proibição.

Aduz a d. Defesa que o réu desconhecia por completo a ilicitude do ato praticado, pois acreditava que poderia utilizar-se da arma de fogo, de uso permitido, para sua defesa pessoal. Entretanto, é pouco crível que uma pessoa de diligência normal desconheça a proibição de se possuir ou de se portar arma de fogo, sem a devida autorização

legal, mormente após a grande repercussão gerada em torno da campanha pelo desarmamento. Ademais, mesmo aqueles que vivem no interior e nas zonas rurais possuem, hoje, amplo acesso aos meios de comunicação, fato que torna injustificável o descumprimento das leis.

Destarte, mantenho a condenação, vez que inexistem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Requer a defesa, ainda, a redução do valor da prestação pecuniária e da multa impostas na sentença.

Entretanto, tenho que não lhe assiste razão.

Primeiramente, necessário ressaltar que a nobre Magistrada tornou definitivas as penas do réu em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia equivalente a um salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Todavia, o preceito secundário do tipo penal descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03 prevê pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Destarte, procedo à correção do erro material, ficando as penas do acusado concretizadas em 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao valor de cada dia-multa, insurge-se a defesa, pugnando pela sua redução para 1/30 do salário mínimo.

Para tanto, aduz que se a pena de multa foi fixada no mínimo, por coerência dever-se-ia adotar o valor do dia-multa também no mínimo legal.

Todavia, tenho que não assiste razão ao apelante.

É cediço que a aplicação da pena de multa segue um critério

bifásico, em que primeiro se fixa o número de dias-multa, valendo-se, para tanto, do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Em seguida, estabelece-se o valor do dia-multa, levando-se em consideração a condição econômica do réu.

Conforme o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"Não se pode esquecer o peculiar fator determinado pela lei para a fixação da pena de multa: o magistrado deve atentar principalmente para a situação econômica do réu (art. 60, caput, CP). Verificando-se que a sua situação financeira é consistente e elevada, deverá ter o valor de cada dia-multa estabelecido em valores superiores a um trigésimo do salário mínimo. Se, feito isso, continuar insuficiente, pode o juiz elevar o número de dias-multa. O mais relevante é que a sanção pecuniária tenha repercussão considerável no patrimônio do condenado. Não se compreende a razão pela qual haja, atualmente, tanto descuido para a fixação da pena de multa, tratando o julgador, por vezes, com minúcia da pena privativa de liberdade e padronizando a multa em '10 dias-multa, calculado cada dia no mínimo legal.

Aliás, conforme a especial hipótese, pode o julgador aumentar a multa até o triplo, se considerar que, em face da situação econômica do réu, seja o seu valor ineficaz, embora aplicado no máximo (art. 60, § 1º, CP)." (Nucci, Guilherme de Souza; "Manual de Direito Penal"; 9ª edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; p. 461/462)

In casu, como bem salientado pela d. Magistrada, a boa situação financeira do réu, o qual se declarou empresário em seu interrogatório (f. 79/80), autoriza a fixação do valor do dia-multa em patamar mais elevado.

Por fim, conforme se verifica à f. 76, a MMª Juíza primeva, após constatar que o acusado preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Todavia, o tipo penal no qual o réu se viu incurso já prevê pena de multa cumulativamente com a sanção corporal. Nesse caso, não se mostra aconselhável e nem mesmo pedagógico substituir a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, vez que, assim, estar-se-ia impondo ao acusado duas reprimendas de cunho pecuniário, quais sejam, a multa prevista no preceito secundário do tipo penal e a pena substitutiva.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão, conforme se verifica do enunciado da Súmula nº 171, in verbis:

"Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa."

Nesse entendimento, observe-se o seguinte julgado do eg. STF:

Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido. (RHC 84040, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 13/04/2004, DJ 30-04-2004 PP-00070 EMENT VOL-02149-09 PP-01786)

Contudo, verifica-se que a defesa não se insurgiu contra a espécie de pena restritiva de direito aplicada na sentença, pugnando, apenas, pela redução do valor fixado. Assim, diante da possibilidade de que a substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direito possa resultar em prejuízo ao apelante, deixo de proceder à substituição, a fim de não incorrer em reformatio in pejus.

E quanto ao pleito defensivo, de redução do valor da prestação pecuniária, tenho que esse não comporta acolhimento.

É cediço que não cabe ao acusado escolher como irá cumprir a

pena, mormente porque as medidas substitutivas não perdem a natureza penal, devendo ser aplicadas, portanto, pelo Juízo competente.

Ademais, ainda que substitutiva, a pena deve exigir do réu algum esforço para o seu cumprimento, proporcionando, assim, de maneira equivalente, a reprovação e a prevenção do delito.

E conforme se verifica do termo de interrogatório acostado à f. 79/80, o apelante se declarou empresário, proprietário do estabelecimento comercial denominado "Theo Motopeças". E nessa oportunidade, Tedy Tarick Silva alegou que é solteiro e que "não tem despesas com uma casa, pois mora com seus pais", f. 79. Declarou, ainda, que possui dinheiro para adquirir drogas, já que se diz usuário de cocaína.

Mister ressaltar, também, que o réu se encontra patrocinado por um dos melhores escritórios de advocacia desta Capital, tudo a confirmar que o apelante possui poder aquisitivo equivalente à pena pecuniária que lhe fora fixada pela nobre Magistrada.

Além disso, o recurso de apelação não é a seara própria para a discussão acerca da dificuldade ou impossibilidade de cumprimento, pelo sentenciado, das penas restritivas de direitos estabelecidas na sentença, vez que tal matéria compete ao Juiz da Execução.

Nessa esteira de entendimento, observe-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

"APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE ESCOLHA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA - ASSUNTO A SER DISCUTIDO NO JUÍZO EXECUTÓRIO. A fixação das penas restritivas fica ao arbítrio do juiz, que escolherá, dentre as elencadas no rol do art. 43 do CPB, as que, na sua concepção, se prestem a alcançar com mais eficiência, as finalidades

de prevenção e reprovação do delito praticado pelo acusado, visando sempre à sua ressocialização. Portanto, não constitui prerrogativa do condenado escolher a pena alternativa que mais lhe convém, devendo a impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da reprimenda ser discutida perante o Juízo da execução a quem cabe decidir qualquer assunto pertinente à forma de cumprimento da medida restritiva imposta. Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 2.0000.00.517770-8/000(1) Relator Desembargador Vieira de Brito; Julgado em 08/11/2005; Publicado em 17/12/2005)

Ressalte-se, ainda, que o pagamento do valor estipulado na sentença a título de prestação pecuniária poderá, em sede de execução, ser parcelado, de modo a não causar prejuízo ao sustento do réu e de sua família.

Portanto, a redução, nesta seara recursal, do valor da prestação pecuniária imposta ao apelante afigura-se inoportuna, nada impedindo, contudo, que o acusado formule o pedido que entender conveniente perante o Juízo da Execução.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, nego provimento ao recurso e, de ofício, corrijo erro material na sentença, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais.

DES. DOORGAL ANDRADA (RELATOR PARA O ACÓRDÃO)

V O T O

Preliminarmente, apenas a título de ressalva, observo que os autos não trazem documentos que asseguram a ocorrência do fato relativo ao tráfico de drogas. Porém, de outro lado, se decorrer de uma mesma investigação com denúncia apenas sobre alguns delitos, os outros passam a ser considerados como arquivamento indireto e somente podem ser investigados através de autorização judicial, por força do art. 18 do CPP e Súmula. 524 do STF.

Neste sentido, o julgado a seguir transcrito:

"EMENTA: Processual penal. Habeas-corpus. Inquérito policial. Arquivamento. Reabertura. Novas provas. Inexistência. CPP, art. 18. Súmula 524/STF. - A regra contida no art. 18, do Código de Processo Penal, somente autoriza a reabertura de procedimento investigatório policial na hipótese de surgimento de novas provas, capazes de, por si só, alterarem ou interferirem na reconstrução das apuradas no inquérito. - "Arquivado o inquérito policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas" (Súmula 524/STF). - Habeas-corpus concedido. Inquérito policial trancado." (STJ - HC 11677 SP 1999/0120624-3 - Sexta Turma - Rel. Min. Vicente Leal 03/05/2000 - Dje 05/06/2000). (grifamos)

"EMENTA: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. JUIZ E MP FEDERAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO (ART-28 DO CPP). A RECUSA DE OFERECER DENUNCIA POR CONSIDERAR INCOMPETENTE O JUIZ, QUE NO ENTANTO SE JULGA COMPETENTE, NÃO SUSCITA UM CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES, MAS UM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO QUE DEVE SER TRATADO A LUZ DO ART-28 DO CPP. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES NÃO CONHECIDO" (STJ CA 12 BA - Tribunal Pleno - Min. Rafael Mayer - 01/04/1982 - DJ 09-12-1983 PP-19415 EMENT VOL-01320-01 PP-00001 RTJ VOL-00108-02 PP-00455). (grifamos)

O arquivamento indireto decorre da observação obrigatória sobre a indisponibilidade da ação penal, além do princípio da publicidade, moralidade, impessoalidade, impostas, seja ao Ministério Público, aos Magistrados e a Autoridade Policial.

Sendo assim, embora alegado tal fato acima acerca do arquivamento indireto do crime de tráfico de drogas não temos na presente apelação provas concretas sobre isso na apelação, devendo prevalecer o voto proferido pelo em. Des. Relator quanto a este item.

Passo ao julgamento.

Em que pese o brilhante voto do em. Des. Relator, peço venia para apresentar divergência em relação à questão aventada no memorial juntado nos autos, cujos argumentos foram sustentados na Tribuna pelo nobre Advogado de defesa.

A meu ver, merece acolhida a preliminar de nulidade, tendo em vista que não foi resguardado à defesa o direito de lhe ser dada vista sobre os documentos juntados pela acusação em suas contrarrazões.

Data venia, encontra-se nos autos às fls. 108/115, os quais são desconhecidos da defesa, o que é inadmissível no Direito Penal moderno.

Não se trata de questão subjetiva, mas de nulidade objetiva absoluta.

Sendo assim, considerando a situação dos autos, a tese preliminar da defesa deve ser acolhida, em virtude de vício que ocasionou o cerceamento de defesa, impondo-se a declaração de nulidade do processo, a partir das folhas do despacho de remessa do presente recurso a este Tribunal (f. 116, inclusive), devendo voltar ao juízo de 1º grau para que a defesa tenha a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pela acusação.

Ninguém pode ser condenado se nos autos constam documentos "secretos", desconhecidos da defesa, atos típicos dos "tempos da inquisição"

E, a meu ver, somente após ser conferido à defesa o direito de resposta, com a análise dos documentos juntados, oportunizando, assim, um contraditório prévio entre as partes, é que o presente recurso estará apto para julgamento.

Destarte, em se tratando de garantias constitucionais como a do contraditório e da ampla defesa, a sua violação é considerada como nulidade absoluta, que pode ser declarada a qualquer tempo, ainda que haja o trânsito em julgado.

Neste sentido, o julgado a seguir transcrito:

" RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. VISTA À PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Ausente impugnação oportuna ao indeferimento da prova realizado em audiência de conciliação, a questão não pode ser discutida em sede de apelação, ante a ocorrência da preclusão.

2. Em atenção ao princípio do contraditório, a juntada de documento novo, mesmo na fase recursal, enseja sempre a manifestação da parte contrária.

3. Recurso especial conhecido em parte e provido." (STJ - REsp 592888 MG 2003/0166093-4 - Quarta Turma - Rel. Min. João Otávio de Noronha 02/02/2010 - DJe 11/02/2010).

Com estas considerações, com redobrada venia, divirjo do eminente Desembargador Relator e ACOLHO A PRELIMINAR suscitada,

para declarar a nulidade do feito, a partir das fl. 116, inclusive, para que seja dada vista à defesa sobre a documentação de fls. 108/115.

DES. CORRÊA CAMARGO

Acompanho os ee. pares quanto à rejeição da primeira preliminar.

Todavia, quanto à segunda preliminar, peço venia ao i. Des. Relator e acompanho o voto proferido pelo e. Des. Revisor.

SÚMULA: "ACOLHERAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, POR MAIORIA, VENCIDO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR"